

1500883-93.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500883-93.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500883-93.2022.8.26.0617 2022/000618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDVALDO CARDOSO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

EDVALDO CARDOSO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e JEREMIAS HERMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 28, da mesma lei.

Segundo narrou a inicial, no dia 06.07.2022, por volta das 08h00, EDVALDO vendeu e trouxe consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 4,85g de cocaína, distribuída em 9 pinos plásticos.

Ainda segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, JEREMIAS

adquiriu e trouxe consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção de cocaína.

Notificados os acusados para apresentação de defesa preliminar, veio aos autos às fls. 122 e 127.

Recebida a denúncia em 29.09.2022 (fl. 129), os réus foram citados pessoalmente (fls. 161 e 163). Em audiência, foi colhida a prova oral e os réus interrogados (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital- fl. 164).

Ao final o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia, observando-se na dosimetria da pena a primariedade do réu; a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em relação a JEREMIAS, a imposição de pena de prestação serviços à comunidade (arquivo digital- fl. 164).

A defesa de EDVALDO, a seu turno, buscou a desclassificação para os delitos dos artigos 28, e 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; e a aplicação do art. 49, do Código Penal, no tocante à multa, por inconstitucional a previsão da lei de tóxicos(fl. 181/190).

A defesa de JEREMIAS, por sua vez, pleiteou a absolvição nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, invocando o princípio da insignificância, e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicando-se penalidade de advertência (fls. 178/180).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Delito do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos – Réu EDVALDO.

O réu EDVALDO, interrogado perante a autoridade policial, disse que era usuário de drogas e confirmou ter vendido uma porção de cocaína a JEREMIAS pelo valor de R\$ 10,00, o qual lhe entregou uma nota de R\$ 20,00, ocasião em que foram abordados pelos policiais (fl. 08)

Em juízo, alterou sua versão e negou a prática delitiva, dizendo que é usuário de drogas e estava na posse de nove porções cocaína, cedendo apenas uma porção para JEREMIAS, a quem já conhecia, recebendo R\$ 20,00 a título de ajuda. Havia comprado doze porções no dia anterior pelo valor de R\$ 150,00 (arquivo digital).

O réu JEREMIAS, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, esclarecendo que era usuário de drogas. Adquiriu um pino de cocaína de EDVALDO, a quem não conhecia, pelo valor de R\$ 10,00, entregando a ele uma nota de R\$ 20,00, porém os policiais chegaram e não houve tempo de receber o troco (arquivo digital).

Os policiais militares ADRIANO RIBEIRO CAMPOS e BEATRIS DE CAMPOS TERRA, ouvidos em juízo, asseveraram, em uníssono, terem visualizado os acusados em atitude suspeita, ocasião em que realizaram a abordagem e apreenderam uma porção de cocaína na posse de JEREMIAS, e oito porções da mesma substância na posse de EDVALDO, além e R\$ 60,00. JEREMIAS confessou informalmente que estava comprando, e EDVALDO, por sua vez, que estava vendendo a droga. Não os conhecia anteriormente. EDVALDO não aparentava ter feito uso de entorpecentes (arquivo digital)

O laudo pericial de fl. 48 atesta que a substância apreendida cuida-se cocaína, que, como se sabe, é droga.

A retratação da confissão policial do réu EDVALDO em juízo, além de não convencer, foi rechaçada pelo conjunto probatório, que confirma a confissão extrajudicial e a existência e autoria delitivas.

De fato, JEREMIAS declarou ter adquirido uma porção de cocaína do acusado, a quem não conhecia, entregando-lhe R\$ 20,00 como forma de pagamento, não recebendo o troco em razão da chegada dos policiais. Ademais, EDVALDO declarou ter realizado troca típica do tráfico de drogas, negando apenas a venda.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes conheciam o réu antes dessa abordagem, não havendo, pois, interesse dele em falsamente incriminá-lo.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

A confissão do réu na fase policial, somada ao relato do corréu JEREMIAS (que também admitiu sua responsabilidade penal pelo delito que lhe fora imputado), e palavra dos policiais, que, em patrulhamento de rotina, apreenderam expressiva quantidade e variedade de drogas na posse direta do acusado (4,85g de cocaína, distribuída em 9 pinos plásticos), além de dinheiro (R\$ 60,00), elementos esses aliados à prova pericial, comprovam, à saciedade, que o réu, vendeu e trazia consigo, a droga ventilada, para fins de tráfico, não havendo se falar em desclassificação para o delito do art. 28 ou 33, § 3º, da Lei de Drogas.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu EDVALDO nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Delito do art. 28, caput, da Lei de Tóxicos – Réu JEREMIAS.

A confissão do réu, aliada às provas oral e pericial, já analisadas, são elementos bastantes a demonstrar existência e autoria delitivas.

A despeito da respeitável argumentação acerca da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Tóxicos, tenho que a norma se subsume, formal e materialmente, à Constituição Federal. Por primeiro, a lei não pune o uso, mas apenas o porte para uso. A circunstância de poder haver desvio dessa droga já é suficiente, a meu ver, para asseverar que não é apenas a vida privada e intimidade do usuário que estão em jogo, mas a saúde pública como um todo. Não bastasse, é necessário repetir o óbvio: sem usuário não haveria traficante. Despiciendo tecer considerações acerca dos malefícios do tráfico na sociedade, responsável pela constituição de uma organização criminosa com movimento de dinheiro superior ao PIB de muitos países, com número de integrantes maior que o de temidos exércitos, o qual a iminente

liberação do porte para uso próprio só engrossará.

Outrossim, o art. 28 da Lei de Tóxicos é norma penal incriminadora, conforme diuturnamente decidido pelo STF:

"POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL: (ART. 28 DA L. 11.343/06 - NOVA LEI DE DROGAS): NATUREZA JURÍDICA DE CRIME. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de 'despenalização', entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou 'abolitio criminis' (C.Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado."

(RE-QO 430105 / RJ - RIO DE JANEIRO/QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO / Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE / Julgamento: 13/02/2007 / Órgão Julgador: Primeira Turma. DJ 27-04-2007 PP-00069 EMENT VOL-02273-04 PP-00729).

Inaplicável o princípio da insignificância, já que a quantidade de droga, a despeito de pequena, é suficiente ao entorpecimento, enquadrando-se a conduta formal e materialmente no tipo penal ventilado.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes.

2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes.

3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos.

4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de

substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

5. Recurso em habeas corpus não provido".

(RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

Presentes, portanto, todas as elementares do delito do art. 28, caput, da Lei de Drogas, e ausentes excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu JEREMIAS em suas penas é impositiva.

Resta fixar as reprimendas.

I) Réu EDVALDO – Do delito do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

As circunstâncias e as consequências do delito foram comuns (4,85g de cocaína, distribuída em nove pinos plásticos, e R\$ 60,00).

A vítima é o Estado.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes.

Deixo de considerar a atenuante relativa à confissão espontânea (Súmula n. 545 do STJ), visto que a pena-base foi fixada no mínimo abstratamente cominado, não podendo, nesta fase, vir aquém.

Inexistem causas de aumento.

Como o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a outras atividades criminosas ou integre organizações desta natureza, reduzo as reprimendas de dois terços (§ 4º do art. 33), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, afora 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Ressalte-se que nada há nos autos a demonstrar que o réu seja traficante habitual, vigendo, em relação a supostos fatos anteriores, a presunção de inocência.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto (art. 33, parágrafo 2º, 'c' e parágrafo 3º, do Código Penal).

Anote-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (§ 5º do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art.

46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 dias-multa, o unitário no piso legal, pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

II) Réu JEREMIAS - Do delito do art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.

A condenação anterior transitada em julgado referente ao processo nº 0001054-19.1995 (fl. 85), cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 09.03.2005 (fl. 86) não forja reincidência, na forma do art. 64, I, do Código Penal. Seria ilógico desconsiderar a condenação para efeito de reincidência e sopesá-la na análise dos antecedentes do acusado. De fato, o Direito Penal moderno não compactua com máculas perenes, vigendo, atualmente, o princípio da temporariedade dos antecedentes.

Assim a jurisprudência:

“(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade.” (HC 110191, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

“EMENTA: PROCESSO CRIMINAL. Suspensão condicional. Transação penal. Admissibilidade. Maus antecedentes. Descaracterização. Reincidência. Condenação anterior. Pena cumprida há mais de 5 (cinco) anos. Impedimento inexistente. HC deferido. Inteligência dos arts. 76, § 2º, III, e 89 da Lei nº 9.099/95. Aplicação analógica do art. 64, I, do CP. O limite temporal de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, aplica-se, por analogia, aos requisitos da transação penal e da suspensão condicional do processo”(HC 86646, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 09-06-2006 PP-00018 EMENT VOL-02236-02 PP-00217 RTJ VOL-00200-02 PP-00933 LEXSTF v. 28, n. 332, 2006, p. 406-414 RT v. 95, n. 853, 2006, p. 504-507 RMDPPP v. 2, n. 12, 2006, p. 83-88).

Nada há de especial em relação às demais balizas do art.59 do Código Penal, pelo que fixo a reprimenda em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

O local de cumprimento da pena será designado pelo juízo da execução, nos termos do parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar:

a) EDVALDO CARDOSO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão (regime aberto), afora 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos;

b) JEREMIAS HERMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses, em local a ser designado pelo juízo da execução, nos termos do parágrafo 5º do mesmo dispositivo legal.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderão os réus recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São José dos Campos, 16 de dezembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA